

RECURSO CÍVEL Nº 5072938-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: BRUNO COELHO SILVA (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. IRPF SOBRE HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E RECONHECIMENTO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. LEI Nº 13.467/17 DISPÕE SOBRE A NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ERESP 1619117/BA) E TEMA 306 TNU. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTE Nº 5001105-09.2020.4.02.5116/RJ.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com manutenção integral da sentença, na forma da fundamentação. Sem custas. Condeno a recorrente vencida em honorários que fixo em 10% do valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5072938-93.2024.4.02.5101

510015595355 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5072938-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: BRUNO COELHO SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso tempestivo interposto pela União - Fazenda Nacional contra sentença que julgou procedente em parte o pedido em ação que versa sobre a incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de Hora Repouso Alimentação (HRA) e verbas similares.

A lide foi julgada nos seguintes termos:

"I - FUNDAMENTAÇÃO:

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.259/2001.

BRUNO COELHO SILVA ajuizou ação, sob o rito dos Juizados Especiais Federais, em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, pleiteando a declaração de inexigibilidade do Imposto de Renda sobre a rubrica "ADICIONAL DE INTERVALO (HRA)", bem como a restituição dos valores retidos a tal título devidamente corrigidos, respeitada a prescrição quinquenal.

Narra, em síntese, que desenvolve sua rotina de labor em turnos ininterruptos de revezamento, não podendo gozar do intervalo para descanso e alimentação após 6 (seis) horas de trabalho, tal como previsto no art. 71 da CLT, ante a especificidade de suas atividades laborais e exigência do empregador.

em consequência, recebe mensalmente a título de Hora Repouso Alimentação (HRA), quantia que, segundo o autor, detém natureza indenizatória, uma vez que visa compensar o prejuízo causado por não gozar de intervalo para descanso e alimentação, razão pela qual não deve haver a incidência de imposto de renda.

Nos termos do art. 153, III, da Constituição Federal, o imposto de renda tem como fato gerador a obtenção de renda ou proventos de qualquer natureza.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 43, de forma a delimitar a previsão constitucional, traz como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; ou proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não considerados como renda.

Nos termos da lei, portanto, depreende-se que aquilo que não constitui renda ou proventos não é, via de regra, passível de incidência do Imposto de Renda, sendo ilegítima a incidência do imposto sobre verbas de caráter indenizatório, ante a sua preponderante natureza reparatória.

Os valores referentes à Hora Repouso Alimentação (HRA) se consubstanciam em pagamentos decorrentes da disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades durante o intervalo destinado ao repouso e alimentação, conforme o art. 2º, parágrafo 2º, da Lei nº 5.811/72:

Art. 2º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o empregado será mantido em seu posto de trabalho em regime de revezamento.

(...)

§ 2º Para garantir a normalidade das operações ou para atender a imperativos de segurança industrial, poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no item II do art. 3º, a disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação.

Referido diploma normativo assegura ao empregado sujeito ao regime de revezamento de oito horas o direito ao pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida em decorrência da necessidade de se garantir a normalidade das operações, ou de atender a imperativos de segurança industrial, referentes à prestação de serviços nas atividades que relaciona em seu art. 1º.

Por sua vez, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) estabelece que, no trabalho contínuo, cuja duração exceda de seis horas, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação de, no mínimo, uma hora, cabendo ao empregador remunerar o empregado por eventual descumprimento dessa determinação, com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. A propósito, vide o artigo 71, §4º, da CLT:

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

(...)

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as parcelas relativas ao intervalo intrajornada e interjornada não usufruídas têm natureza salarial, de modo que incidem sobre elas a tributação nas situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.467, de 13 de julho de 2017, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de Hora Repouso Alimentação - HRA, prevista nos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

2. O acórdão embargado consignou que tal verba "[...] reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória, pois seu escopo é recompor direito legítimo do empregado suprimido em virtude das vicissitudes da atividade laboral, assumindo perfil de genuína compensação, de verdadeira contrapartida a que o empregador está

obrigado, por lei, a disponibilizar ao obreiro, em virtude da não fruição do direito ao intervalo para refeição e repouso que lhe é garantido, imprescindível ao restabelecimento do seu vigor físico e mental".

3. Partindo da premissa de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza indenizatória, concluiu que sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária patronal (art. 22, I, da Lei 8.212/1991).

4. O julgado apontado como paradigma, por sua vez, assentou: "a 'Hora Repouso Alimentação - HRA' [...] é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador", configurando, assim, "retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991".

5. É patente a similitude fática entre os acórdãos confrontados, bem como a divergência entre as soluções jurídicas adotadas em cada caso.

PRECEDENTES DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMA DO STJ.

6. A Primeira Turma reconheceu que a HRA reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória em mais um precedente: REsp 1.328.326/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p./ acórdão Min.Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.5.2017.

7. Na Segunda Turma, prevalece a compreensão de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza remuneratória, devendo incidir sobre ela a contribuição previdenciária patronal. Precedentes: AgInt no REsp 1.727.114/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019; AgInt no AREsp 1.122.223/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.8.2019; AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016; REsp 1.144.750/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2011; EDcl no REsp 1.157.849/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.5.2011.

NATUREZA JURÍDICA DA HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO

8. A Hora Repouso Alimentação - HRA constitui verba paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei 5.811/1972

9. O pagamento por essa "disponibilidade do empregado" é feito nos termos dos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

10. A Hora Repouso Alimentação - HRA é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador. Ou seja, o trabalhador recebe salário normal pelas oito horas regulares e HRA pela 9ª (nona) hora, em que ficou à disposição da empresa.

11. Inexiste simplesmente supressão da hora de descanso, hipótese em que o empregado ficaria 8 horas contínuas à disposição da empresa e receberia por 9 horas (haveria "indenização" pela hora de descanso suprimida).

12. O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga à hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária.

13. Ao contrário do afirmado no acórdão embargado, **a HRA possui nítida natureza remuneratória, submetendo-se à tributação pela contribuição previdenciária patronal, nos termos dos arts. 22, I, e 28 da Lei 8.212/1991.**

14. Tratando da incidência da contribuição previdenciária sobre a HRA, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.039.689/RS (Rel. Min.Dias Toffoli, DJe 11.9.2017), afirmou: "Desse modo, não diverge o Tribunal a quo do entendimento da Corte no sentido da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre verbas remuneratórias, conforme ficou deliberado no julgamento do RE nº 565.160/SC (Tema 20 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet). Verifico que, nessa decisão, a Corte se debruçou sobre o alcance da expressão 'folha de salários', contida no art. 195, I, 'a', da Constituição Federal, que é base de cálculo da exação em tela".

15. Em obiter dictum, impende ressaltar que a redação do art. 71, § 4º, da CLT foi alterada pela Lei 13.467/2017: "A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho".

16. **A compreensão esposada abrange apenas os pagamentos e recolhimentos realizados antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017, uma vez que a nova redação do art. 71, § 4º, da CLT não foi objeto de discussão no presente caso.**

CONCLUSÃO

17. Embargos de Divergência providos, para **reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a Hora Repouso Alimentação - HRA, até a entrada em vigor da Lei**

Como visto, a Lei nº 13.467/2017, no art. 71, § 4º, trouxe alterações à CLT e dispôs expressamente que o pagamento de intervalo intrajornada suprimido tem natureza indenizatória:

"Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.

§ 2º - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.

§ 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (grifou-se)

A questão foi objeto de apreciação pela Turma Nacional de Uniformização (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0520381-15.2020.4.05.8400/RN), oportunidade na qual fixada a seguinte tese (Tema 306):

"Com o advento da Lei nº 13.467, de 13/07/2017, que deu nova redação ao § 4º do art. 71 da CLT e estabeleceu expressamente a natureza indenizatória do pagamento operado pela supressão do intervalo intrajornada, habitualmente conhecido como Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA), em conformidade com a proteção constitucional à saúde do trabalhador (arts. 7º, XXII, 194, caput, 197 e 200, II, bem como art. 5º, § 2º c.c. arts. 4º e 5º da Convenção 155 da OIT, incorporada ao direito interno pelo Decreto n. 1.254/94, hoje consolidada no Decreto n. 10.088/2019 e o art. 7º, do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, incorporado ao direito interno pelo Decreto n. 591/92), não incide imposto de renda sobre a verba paga a tal título" (grifo nosso).

Em que pesem os argumentos lançados pela ré em sede de contestação, destaco que as Turmas Recursais do Rio de Janeiro acompanham o entendimento da TNU, valendo citar os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. IRPF SOBRE HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E RECONHECIMENTO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. LEI Nº 13.467/17 DISPÕE SOBRE A NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ERESP 1619117/BA) E TEMA 306 TNU. PUIL/STJ Nº 3742. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTE Nº 5001105-09.2020.4.02.5116/RJ.

DECISAO: A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas. Condeno a recorrente vencida em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

(TRF2 , RECURSO CÍVEL, 5094663-75.2023.4.02.5101, Rel. CYNTHIA LEITE MARQUES , Juízo Gestor das Turmas Recursais , Rel. do Acordao - CYNTHIA LEITE MARQUES, julgado em 12/12/2023, Dje 13/12/2023 13:12:11)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE O ADICIONAL HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA) - A TNU, NO JULGAMENTO DO PEDILEF 0520381-15.2020.4.05.8400/RN (TEMA 306), FIRMOU A TESE: "COM O ADVENTO

DA LEI Nº 13.467, DE 13/07/2017, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 71 DA CLT E ESTABELECEU EXPRESSAMENTE A NATUREZA INDENIZATÓRIA DO PAGAMENTO OPERADO PELA SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA, HABITUALMENTE CONHECIDO COMO ADICIONAL HORA DE REPOUSO E ALIMENTAÇÃO (AHRA), EM CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE DO TRABALHADOR (ARTS. 7º, XXII, 194, CAPUT, 197 E 200, II, BEM COMO ART. 5º, § 2º C.C. ARTS. 40 E 50 DA CONVENÇÃO 155 DA OIT, INCORPORADA AO DIREITO INTERNO PELO DECRETO N. 1.254/94, HOJE CONSOLIDADA NO DECRETO N. 10.088/2019 E O ART. 7º, DO PACTO INTERNACIONAL RELATIVO AOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS, DE 1966, INCORPORADO AO DIREITO INTERNO PELO DECRETO N. 591/92), NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA PAGA A TAL TÍTULO" - PUIL 3742/STJ SEM DECISÃO - AGRAVO DA UNIÃO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

DECISAO: A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO AGRAVO interposto pela União e de a ele NEGAR PROVIMENTO para MANTER a decisão monocrática agravada. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

(TRF2 , RECURSO CÍVEL, 5002848-76.2023.4.02.5107, Rel. MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO , 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro , Rel. do Acordao - MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO, julgado em 19/06/2024, DJe 19/06/2024 15:39:52)

Assim, em deferência à jurisprudência já consolidada no âmbito dos Juizados Especiais Federais, entendo que os valores percebidos a título de Hora Repouso Alimentação (HRA) detém natureza indenizatória, não devendo sofrer a incidência de imposto de renda.

No que toca à repetição de indébito, observo que o art. 168, I, do CTN, combinado com o artigo 3º da LC nº 118/2005, prevê um prazo prescricional de cinco anos, iniciando-se a partir do efetivo pagamento de cada exação.

Outrossim, na análise da prescrição deve-se observar como termo final a data do ajuizamento da demanda.

Também destaco que a natureza indenizatória da verba restou explicitada com a Lei nº 13.467/2017, a qual foi publicada em 13/07/2017, e passou a vigorar em 13/11/2017, na forma do seu art. 6º.

Portanto, considerando que a demanda foi proposta em 17/09/2024 e que a nova lei passou a vigorar a partir de 13/11/2017, resta prescrita a pretensão de se obter a restituição das parcelas pagas anteriormente a **18/09/2019**.

Ressalto que, para fins de indébito tributário, as parcelas devidas deverão ser remuneradas, desde quando descontadas, pelo índice correspondente à Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, o qual representará, simultaneamente, atualização monetária e juros de mora, não podendo incidir cumulativamente com outro índice de correção monetária.

Quanto ao cálculo dos valores a serem restituídos, não deverá ser promovida a simples devolução da quantia isenta, uma vez que a apuração do Imposto de Renda Pessoa Física decorre de um complexo sistema de informações, deduções, abatimento e comparação entre valores.

Assim, se sobre determinada verba incidiu indevidamente imposto de renda, esse imposto foi utilizado na declaração de ajuste para diminuir o valor do imposto a pagar.

Além disso, as verbas indevidamente tributadas devem deixar o campo relativo aos rendimentos tributáveis e passar ao campo dos rendimentos não-tributáveis, sendo possível a existência de vários fatores de dedução (como a Declaração Simplificada ou Completa) que precisam ser levados em consideração a fim de se verificar eventuais restituições já feitas ao contribuinte.

Dessa forma, caberá à parte autora, na fase de liquidação, apresentar as declarações de imposto de renda pertinentes, a fim de que o imposto a ser devolvido seja calculado levando-se em consideração todos os elementos ali presentes.

Finalmente, reputo dispensável a remessa dos autos à Contadoria, já que o caso envolve cálculo aritmético simples, que pode ser realizado em sede de execução do julgado.

II - DISPOSITIVO:

Do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO** e determino a **EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO**, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a. **RECONHECER** o direito do autor de não ser compelido ao recolhimento de Imposto de Renda referente aos valores percebidos a título de Hora Repouso Alimentação (HRA).

b. **RECONHECER** o direito do autor de ter restituídos os valores indevidamente recolhidos a título de Hora Repouso Alimentação (HRA), rubricas "ADICIONAL DE INTERVALO (HRA)", observando-se o prazo prescricional quinquenal, contado retroativamente a partir da data de ajuizamento da presente demanda, em 17/09/2024, e a incidência da Taxa **SELIC** desde o pagamento indevido.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Em caso de interposição de recurso inominado, intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do §2º do art. 42 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos às Turmas Recursais, nos termos do Enunciado 79 do FOREJEF da 2ª Região, combinado com o artigo 1.010, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, intime-se a UNIÃO para que indique o valor a ser requisitado, nos termos do Enunciado nº 52 das Turmas Recursais¹. Cumprido, expeça-se RPV, nos termos do art. 17 da Lei 10.259/01 e da Resolução nº 822/2023, do Conselho da Justiça Federal.

Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos, oportunamente."

Em suas razões, a Fazenda Nacional reafirma, em síntese, a legitimidade da incidência do imposto de renda sobre os valores pagos a título de HRA. No mais, sustenta que o acórdão da TNU que julgou o Tema nº 306 - que trata da matéria discutida nesta demanda - ainda não transitou em julgado, razão por que o entendimento nele adotado ainda pode ser aplicado. Pede a reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido ou, então, que o julgamento do recurso seja sobrestado até que apreciado o PUIL/STJ nº 3742.

É o breve relatório.

VOTO

A temática em exame foi apreciada por esta 8ª Turma Recursal em sessão realizada em 18/08/2020 (Processo nº 5001105-09.2020.4.02.5116/RJ, de Relatoria do saudoso Dr. LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA). Segue trecho do julgamento:

'PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DEMAIS TRIBUTOS. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PARA RECONHECER TAL RUBRICA COMO INDENIZATÓRIA, DE MODO QUE, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17 NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA SOBRE ELA, CONFORME O ENTENDIMENTO SUGERIDO POR PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ERESP 1619117/BA). RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

A CLT prevê no artigo 71 que quando o período para repouso e alimentação não for concedido, a empresa tem de remunerar o funcionário pelo tempo correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal de trabalho.

A problemática reside em saber qual a natureza dos pagamentos: se esta é indenizatória ou remuneratória. No primeiro caso, não há tributação, já que não se trata de salário. No segundo caso, deverá haver tributação.

Pois bem, quanto ao tema o STJ já havia firmado entendimento de que as parcelas relativas ao intervalo intrajornada e interjornada não usufruídos tem sua natureza salarial e incidem sobre elas a tributação, nas situações ocorridas antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, a Lei 13.467/2017.

Assim, não possuindo natureza indenizatória, mas salarial, é possível a incidência da contribuição previdenciária e do imposto de renda, em princípio.

Quanto ao tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de Hora Repouso Alimentação - HRA, prevista nos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

2. O acórdão embargado consignou que tal verba "[...] reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória, pois seu escopo é recompor direito legítimo do empregado suprimido em virtude das vicissitudes da atividade laboral, assumindo perfil de genuína compensação, de verdadeira contrapartida a que o empregador está obrigado, por lei, a disponibilizar ao obreiro, em virtude da não fruição do direito ao intervalo para refeição e repouso que lhe é garantido, imprescindível ao restabelecimento do seu vigor físico e mental".

3. Partindo da premissa de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza indenizatória, concluiu que sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária patronal (art. 22, I, da Lei 8.212/1991).

4. O julgado apontado como paradigma, por sua vez, assentou: "a 'Hora Repouso Alimentação - HRA' [...] é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador", configurando, assim, "retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991".

5. É patente a similitude fática entre os acórdãos confrontados, bem como a divergência entre as soluções jurídicas adotadas em cada caso.

PRECEDENTES DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMA DO STJ 6. A Primeira Turma reconheceu que a HRA reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória em mais um precedente: REsp 1.328.326/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p./ acórdão Min.

Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.5.2017.

7. Na Segunda Turma, prevalece a compreensão de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza remuneratória, devendo incidir sobre ela a contribuição previdenciária patronal. Precedentes: AgInt no REsp 1.727.114/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019; AgInt no AREsp 1.122.223/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.8.2019; AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016; REsp 1.144.750/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2011; EDcl no REsp 1.157.849/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.5.2011.

NATUREZA JURÍDICA DA HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO 8. A Hora Repouso Alimentação - HRA constitui verba paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei 5.811/1972.

9. O pagamento por essa "disponibilidade do empregado" é feito nos termos dos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

10. A Hora Repouso Alimentação - HRA é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador. Ou seja, o trabalhador recebe salário normal pelas oito horas regulares e HRA pela 9ª (nona) hora, em que ficou à disposição da empresa.

11. Inexiste simplesmente supressão da hora de descanso, hipótese em que o empregado ficaria 8 horas contínuas à disposição da empresa e receberia por 9 horas (haveria "indenização" pela hora de descanso suprimida).

12. O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga à hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária.

13. Ao contrário do afirmado no acórdão embargado, a HRA possui nítida natureza remuneratória, submetendo-se à tributação pela contribuição previdenciária patronal, nos termos dos arts. 22, I, e 28 da Lei 8.212/1991.

14. Tratando da incidência da contribuição previdenciária sobre a HRA, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.039.689/RS (Rel. Min.Dias Toffoli, DJe 11.9.2017), afirmou: "Desse modo, não diverge o Tribunal a quo do entendimento da Corte no sentido da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre verbas remuneratórias, conforme ficou deliberado no julgamento do RE nº 565.160/SC (Tema 20 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet). Verifico que, nessa decisão, a Corte se debruçou sobre o alcance da expressão 'folha de salários', contida no art. 195, I, 'a', da Constituição Federal, que é base de cálculo da exação em tela".

15. Em obiter dictum, impende ressaltar que a redação do art. 71, § 4º, da CLT foi alterada pela Lei 13.467/2017: "A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho".

16. A compreensão esposada abrange apenas os pagamentos e recolhimentos realizados antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017, uma vez que a nova redação do art. 71, § 4º, da CLT não foi objeto de discussão no presente caso.

CONCLUSÃO 17. Embargos de Divergência providos, para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a Hora Repouso Alimentação - **HRA, até a entrada em vigor da Lei 13.467/2017.**

(EResp 1619117/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 08/05/2020)

Todavia, como ressaltado no julgado acima, a Lei nº 13.467/2017, no artigo 71, § 4º trouxe alterações na CLT e dispôs expressamente que o pagamento de intervalo intrajornada suprimido tem natureza indenizatória.

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.

§ 2º - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.

§ 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, **de natureza indenizatória**, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.

(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

§ 5º O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele estabelecido no § 1º poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos

rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

Assim, não incide o imposto de renda, a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/17.

No entanto, a par da modificação introduzida pela legislação trabalhista entende-se que a 'Hora Repouso Alimentação - HRA' é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador, configurando retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991.

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Tema 20. RE 565.160. Salário-maternidade. Salário-paternidade. Férias usufruídas. Horas extras. Adicionais de horas extras, noturno, de periculosidade e de insalubridade. Atestados médicos/faltas justificadas. Auxílio-alimentação (em pecúnia). Repouso semanal remunerado e feriados. Intrajornada. Décimo terceiro salário. Salário família. Abono de férias. Auxílio educação. Auxílio casamento e auxílio funeral. Auxílio-creche. Abono de faltas. Abono assiduidade. Adicional de transferência. Férias usufruídas. Adicional constitucional sobre férias gozadas. Primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente. Aviso prévio indenizado. [...] 4. **Incide contribuição previdenciária sobre salário maternidade, salário-paternidade, férias usufruídas, horas extras, adicionais de horas extras, noturno, de periculosidade e de insalubridade, atestados médicos/faltas justificadas, auxílio-alimentação (em pecúnia), repouso semanal remunerado e feriados, intrajornada, décimo terceiro salário, abono de faltas, adicional de transferência.** (TRF4 5003384-65.2014.4.04.7203, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 19/12/2017)

Com efeito, a referida rubrica será incorporada aos proventos de aposentadoria, já que faz parte do seu cálculo, mesmo na legislação atual."

No mesmo sentido é o Tema 306 da TNU:

"Com o advento da Lei nº 13.467, de 13/07/2017, que deu nova redação ao § 4º do art. 71 da CLT e estabeleceu expressamente a natureza indenizatória do pagamento operado pela supressão do intervalo intrajornada, habitualmente conhecido como **Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA)**, em conformidade com a proteção constitucional à saúde do trabalhador (arts. 7º, XXII, 194, caput, 197 e 200, II, bem como art. 5º, § 2º c.c. arts. 4º e 5º da Convenção 155 da OIT, incorporada ao direito interno pelo Decreto n. 1.254/94, hoje consolidada no Decreto n. 10.088/2019 e o art. 7º, do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, incorporado ao direito interno pelo Decreto n. 591/92), **não incide imposto de renda sobre a verba paga a tal título.**"

A despeito da alegação da União sobre a impossibilidade de aplicação imediata do Tema 306, não houve determinação de suspensão de julgamentos dos processos com a mesma temática, destacando que a questão em debate será novamente apreciada em razão do PUIL/STJ n. 3742, de modo que nada obsta a aplicação do referido Tema, o que tampouco inviabilizará a hipótese de retratação pela Turma da decisão ora proferida, se assim decidir a Corte Superior.

Não há o que acolher no recurso. A sentença é clara, devidamente fundamentada e deve ser mantida por seus próprios fundamentos e pelos acima expendidos.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com manutenção integral da sentença, na forma da fundamentação. Sem custas. Condeno a recorrente vencida em honorários que fixo em 10% do valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

1. Enunciado 52: "Nas ações que tenham por objeto prestações de trato sucessivo, a sentença ou acórdão que julgar procedente o pedido determinará a implantação administrativa da prestação, podendo o juiz ordenar que a parte ré forneça os elementos de cálculo ou indique o valor dos atrasados, para o fim de pagamento na forma do art. 17 da Lei 10.259/01". (Aprovado na Sessão Conjunta realizada em 26/05/2006, e publicado no DOERJ de 01/06/2006, pág. 5, Parte III)